

刑法
No97

H29-5

(配点：3)

月 日

月 日

正当防衛及び緊急避難に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 正当防衛は、法益の侵害が現に存在している場合のほか、法益の侵害が間近に差し迫っている場合にも成立する余地があるが、緊急避難は、危難が間近に差し迫っている場合に成立する余地はない。
2. 正当防衛が成立するためには、防衛行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを要するから、防衛行為によって生じた害が避けようとした害の程度を超えた場合に正当防衛が成立する余地はない。
3. 正当防衛が成立する行為を避けるために相手方又は第三者の法益を侵害した場合、緊急避難が成立する余地があるが、正当防衛が成立する余地はない。
4. 過剰避難について、その刑を減軽も免除もしないことはできるが、過剰防衛については、その刑を減軽又は免除しなければならない。
5. 自然現象によって生じた法益侵害を避けるために第三者の法益を侵害した場合、緊急避難が成立する余地があるが、正当防衛が成立する余地はない。

No97	正当防衛及び緊急避難		正答率
H29-5	正 解	3、5（順不同）	91%

1 誤っている

最判昭24.8.18は、「36条にいわゆる急迫の侵害における『急迫』とは、法益の侵害が間近に押し迫つたこと……を意味する、……37条にいわゆる『現在の危険』についても、ほぼこれと同様」としている。「現在の危険」の内容は、36条1項の「急迫」と同一のものと解されており、危険が現在する場合に限らず、間近に押し迫っている場合でも、緊急避難が成立する余地がある。

2 誤っている

正当防衛が成立するためには、防衛行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有することが必要であるので、前段は正しい。しかし、最判昭44.12.4は、防衛行為の相当性につき、「自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること」とした上で、「反撃行為が……侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であつても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではない」としている。よって、防衛行為によって生じた害が避けようとした害の程度を超えた場合にも正当防衛が成立する余地はある。よって、後段は誤っている。

3 正しい

緊急避難は現在の危険に対する行為であることを要する。「危険」とは、法益に対する侵害又はその危険のある状態をいい、「正」対「正」の行為について緊急避難が成立し得る。正当防衛が成立する行為であっても、法益に対する侵害に当たり得る以上「危険」に当たり、緊急避難が成立する余地はある。よって、前段は正しい。他方、正当防衛は、急迫不正の侵害に対する行為であることを要し、「不正」とは違法をいう。相手方の行為に正当防衛が成立する以上、行為の違法性は阻却され、相手方は「正」となり、これに対する防衛行為は「正」対「正」の関係となる。そのため、正当防衛が成立する相手方の行為に対する行為に正当防衛が成立することはない。防衛行為が第三者に対して生じたとしても、第三者も「正」である以上、「正」対「正」となり、正当防衛は成立しない。よって、正当防衛が成立する行為は急迫不正の侵害には当たらず、当該行為を避けるために相手方又は第三者の法益を侵害した場合、正当防衛が成立する余地はないので、後段も正しい。

4 誤っている

防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減輕し、又は免除することができる（36条2項）。よって、過剰防衛が成立する場合、その刑を減輕又は免除しないことができ、刑の減輕又は免除をしなければならないわけではない。

5 正しい

緊急避難は、現在の危険に対する行為であることを要する。自然現象も法益に対する侵害状態なので危険に当たる。そのため、自然現象によって生じた法益侵害を避けるために、第三者の法益を侵害した場合、「正」である自身に対する法益侵害を避けるため、「正」である第三者の法益を侵害することとなり、「正」対「正」の関係が認められ、緊急避難が成立する余地がある。他方で、正当防衛は、急迫不正の侵害に対する行為であることを要する。自然現象によって生じた法益侵害は、違法性がないため不正の侵害に当たらない。そのため、自然現象によって生じた法益侵害を避けるために第三者の法益を侵害した場合に、正当防衛は成立する余地がない。

以上により、正しい記述は3と5であり、したがって、正解は肢3と肢5（順不同）となる。